

1501069-96.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs.

Comprovado o tráfico de drogas, decreto o perdimento dos celulares, dinheiro e veículo apreendidos, em favor da União, na forma requerida. Com efeito, não foi comprovada a origem lícita dos bens apreendidos e com relação ao veículo basta que seja utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes para a decretação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-400

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501069-96.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501069-96.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170642/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 25731286 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2170642 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS VINICIUS DE FARIA CARDOSO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

VISTOS.

PAULO SERGIO VILANUEVA TORRES e LUCAS VINICIUS DE FARIA CARDOSO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o art. 29 do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 23 de junho de 2022, por volta das 20 horas, na Avenida Orlando Canuto da Silva, esquina com a Rua Elso Paglione e na Rua Leodoro

Bernardo, nº 353, Bairro Dignidade, ambos endereços nesta cidade e comarca, os acusados, em conluio e unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito e traziam consigo, para fins de comercialização a terceiros, 25 tijolos de maconha, pesando 6.623,000 gramas, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS.

Narra a denúncia que na data dos fatos, policiais, em patrulhamento na Rua Elso Paglione, avistaram um veículo Renault/Sandero, cor branca, estacionado, o qual, percebendo a aproximação da viatura, sem motivo que justificasse, arrancou em velocidade, o que chamou muito a atenção a ponto de serem interceptados e abordados, apesar da tentativa de fuga. No interior do veículo havia dois indivíduos, sendo o motorista identificado como Lucas Vinícius de Faria Cardoso e o passageiro Paulo Sérgio Vilanueva Torres. Em poder de Lucas foi encontrada a quantia de R\$ 52,00 e três aparelhos de telefones celulares. Em poder de Paulo localizaram a quantia de R\$ 550,00 e um telefone celular, contudo, ao vistoriarem o interior do veículo, encontraram um saco contendo em seu interior nove tijolos de maconha, todos embalados individualmente e em forma compacta. Narra que indagados, Lucas afirmou que nada mais possuía em seu poder, ao passo que Paulo confessou que em sua residência havia mais drogas. Diante disso se deslocaram até a Rua Leodoro Bernardo, nº 353, Bairro Dignidade, onde reside o acusado Paulo, e lá encontraram mais 16 tijolos menores de maconha, que informaram ser potencializado e conhecido também por haxixe. Narra que no interior da casa foram encontrados petrechos para manuseio da droga, tais como uma faca suja de maconha, duas balanças, sendo uma maior e outra menor, além de um rolo de plástico filme, plásticos pequenos com fechamento zip, bem como um martelo com a ponta de borracha. Ao serem entrevistados para melhor esclarecerem os fatos, ambos foram taxativos em afirmar que todo o material, incluindo a droga, pertencia ao acusado Lucas e Paulo prestava serviços a ele, que guardava, cortava, embalava, transportava e entregava a droga, e recebia mensalmente o valor de R\$ 3.000,00 para tal serviço. Consta ainda que os acusados compartilhavam a posse e propriedade das drogas encontradas e realizavam o tráfico de entorpecentes conjuntamente.

Notificados (fls. 130 e 140), os acusados apresentaram defesa preliminar (fls. 143/147 e 175/178).

Recebida a denúncia (fls. 196/199), os réus foram citados.

Durante a instrução, depois de ouvidas as testemunhas, os réus foram interrogados. A instrução foi encerrada e nos debates orais o Ministério Público reiterou o pedido condenatório contido na denúncia, ao passo que as Defesas sustentaram, em preliminar, nulidade da revista pessoal, inviolabilidade de domicílio e não foi respeitado o direito ao silêncio e, no mérito, pediram a absolvição e subsidiariamente o reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 241/248).

É o relatório.

DECIDO.

Primeiro, quanto às preliminares, nenhuma ilicitude há de ser reconhecida.

A revista pessoal é permitida (art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal) e, neste caso, havia fundada suspeita. Com efeito, policiais militares, durante patrulhamento ostensivo em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, ante a conduta do motorista que, ao avistar a viatura, empreende manobra brusca, em velocidade, resolvem pela abordagem e revista pessoal. Está, portanto, justificada a abordagem e a revista pessoal e no veículo.

Ademais, com a abordagem dos acusados e revista no veículo, é encontrada quantidade

expressiva de drogas e o corréu Paulo confessa informalmente aos policiais que havia mais drogas em sua casa, levando-os até o local e abrindo as portas da residência.

É necessário ressaltar que o crime de tráfico de drogas é permanente, logo, possível o ingresso na residência do réu, quando existirem indícios da prática de crime. Muito embora a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI, diga ser o lar asilo inviolável, essa norma traz exceções, como na hipótese de prisão em flagrante delito, o que se verificou nesse caso. Ademais, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar em 05/11/2015 o Recurso Extraordinário nº 603.616, representativo da controvérsia, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, dotado de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (destaquei).

Neste caso havia fundadas razões, mormente em razão do encontro de drogas no veículo e, chegando à residência, eram visíveis pela janela da casa os demais entorpecentes apreendidos.

Além do mais, em decisão recente, a Ministra Rosa Weber, assentou que “A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado” (STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 213.852/RJ, 1ª Turma, j. 30 de maio de 2022).

No tocante ao direito ao silêncio o “Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em

silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo. (...) Deve se ter em consideração igualmente que a garantia constitucional de não produzir provas contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (nemo tenetur se detegere), 'não pode ser interpretada no sentido de se vedar a produção de qualquer tipo de prova sem a concordância do acusado. Entendimento contrário implicaria o reconhecimento da impossibilidade de se realizar, sem o consentimento do réu, a revista pessoal, o reconhecimento de pessoas, a interceptação telefônica, etc'" (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/10/2016, DJe 07/11/2016).

Assim sendo, neste caso, eventual falta de advertência do direito de permanecer em silêncio não acarretou nulidade, muito menos prejuízo à defesa, uma vez a suposta confissão sem a referida advertência teria ocorrido no momento da abordagem policial, sendo certo que, na delegacia, os réus foram advertidos dos seus direitos constitucionais e se valeram da prerrogativa de permanecerem calados, afirmando que somente iriam se pronunciar em juízo e, na audiência de instrução e julgamento, ficaram parcialmente em silêncio, respondendo apenas as perguntas do seu respectivo defensor.

Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Os acusados permaneceram em silêncio no auto de prisão em flagrante e em Juízo exerceram parcialmente ao direito ao silêncio, respondendo apenas às perguntas de seus defensores.

O acusado LUCAS negou qualquer envolvimento com as drogas, afirmando que conhecia Paulo há aproximadamente um ano, pois jogavam bola juntos. Paulo lhe pediu para levá-lo até a UPA, alegando que estava com a perna machucada e, como estava disponível, foi até a casa de Paulo com mototáxi. No local Paulo lhe pediu para dirigir o veículo, justificando que estava com a perna machucada. Durante o trajeto Paulo pediu para passar em um lugar, mas logo em seguida foram abordados pelos policiais. Confirmou que os policiais localizaram drogas no interior do carro, mas frisou que não tinha conhecimento da droga. Já tinha sido detido por um dos policiais em outra ocasião. Permaneceu no local enquanto Paulo foi levado por outra viatura.

Por sua vez, o a acusado PAULO disse residir no país há aproximadamente oito anos. No dia anterior à prisão foi jogar bola, mas acabou se machucando e resolveu ir embora. Quando deixava o local encontrou um conhecido e durante a conversa acabou relatando que enfrentava sérias dificuldades financeiras, inclusive com pensões atrasadas. Referida pessoa lhe ofertou a quantia de R\$ 2.000,00 para armazenar drogas. Acabou aceitando a oferta, pois enfrentava sérias dificuldades financeiras. Afirmou que foi a primeira vez que se envolveu com entorpecentes. Na data dos fatos pretendia ir até a UPA e, como não podia dirigir, pediu ao corréu Lucas para levá-lo, sendo que no trajeto foram abordados pelos policiais. O veículo pertencia a sua genitora e o pegou sem pedir permissão. Feita a abordagem os policiais logo localizaram a droga no interior do veículo. Lucas não tinha conhecimento da droga. Ficou com muito medo, sem reação, mas foi ameaçado pelos policiais, obrigado a indicar sua casa, sob pena deles apresentarem outros entorpecentes para acusá-lo. Negou ter sido orientado pelos policiais que poderia permanecer em silêncio. Levou os policiais até sua casa, onde foi obrigado a abrir o imóvel. Possui quatro filhos.

O policial Rodrigo Antônio Dias ratificou sua narrativa anterior, afirmando que durante patrulhamento avistaram um veículo Renault/Sandero estacionado, o qual arrancou em velocidade ao notar a aproximação da viatura, sendo interceptado e abordado. No interior do veículo havia dois indivíduos, sendo o corréu Lucas o motorista, tendo o corréu Paulo como passageiro. Apurou que o veículo era do réu Paulo. Com o réu Lucas foi encontrada a quantia de R\$ 52,00 e três celulares, e com

o réu Paulo a quantia de R\$ 550,00 e um celular. No interior do veículo encontraram um saco contendo nove tijolos de maconha embalados individualmente e em forma compacta. Questionados, o corréu Lucas afirmou que nada mais possuía em seu poder, ao passo que Paulo confessou que em sua residência havia mais droga. Foram então até a Rua Leodoro Bernardo nº 353, no Bairro Dignidade, residência de Paulo, e lá encontraram mais 16 tijolos menores de maconha, que os acusados informaram ser potencializado e conhecido também por haxixe. No interior da casa também encontraram petrechos para manuseio da droga, tais como uma faca suja de maconha, duas balanças, sendo uma maior e outra menor, além de um rolo de plástico filme, plásticos pequenos com fechamento zip e um martelo com a ponta de borracha. Os acusados foram unânimes em afirmar que todo o material, incluindo a droga, pertencia ao acusado Lucas e o acusado Paulo lhe prestava serviços, sendo que guardava, cortava, embalava, transportava e entregava a droga e, para tanto, recebia mensalmente o valor de R\$ 3.000,00. Posteriormente, o corréu Lucas confirmou os fatos, assumindo que pagava para o corréu Paulo. Esclareceu que os acusados tentaram deixar o local rapidamente, mas logo foram abordados, não sendo possível identificar os ocupantes sem a abordagem. Não conhecia os acusados. Não foram até a casa do corréu Lucas porque os dois acusados confirmaram que a droga apreendida na casa do réu Paulo pertencia ao réu Lucas e este também negou que mantivesse drogas em sua casa. Afirmou que Paulo autorizou as buscas na residência, inclusive apontou o imóvel e o local onde a droga estava, contudo, não se recordou se colheram autorização por escrito. Frisou que pela janela era possível avistar as drogas na residência. O veículo estava em nome da genitora de Paulo. Os nove tijolos de maconha estavam sobre o banco traseiro, dentro de um saco plástico.

No mesmo sentido é a narrativa do policial Bruno Balsanelli Dionísio, confirmando que o local da abordagem é conhecido ponto de narcotráfico. Os tijolos de maconha estavam sobre o banco traseiro e prontamente o corréu Lucas assumiu a propriedade da droga, indicando que o corréu Paulo era o responsável por armazenar a droga em sua casa, bem como fazer algumas entregas. Na casa do corréu Paulo apreenderam mais entorpecentes e diversos petrechos. Já conhecia o acusado Lucas, indicando que tinha participado de outra prisão dele. A residência de Paulo não possuía portão e logo pela janela já foi possível avistar a droga.

A testemunha Pâmela Branco disse que não presenciou a abordagem. Conheceu o corréu Paulo por meio do aplicativo Uber, tornando-se amigos. Confiava no corréu Paulo e chegou a indicá-lo para amigos e familiares.

A testemunha Gilberto Anísio afirmou que já trabalhou com o acusado Paulo na instalação de forros e divisórias por cinco ou seis meses. Não presenciou a abordagem. Confirmou que Paulo também era motorista de aplicativo.

Ante o exposto, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a condenação.

A materialidade delitiva está comprovada pelos documentos de fls. 27/32 (boletim de ocorrência), fls. 40/41 (auto de exibição e apreensão), fls. 45/50 (laudo de constatação), fls. 51/54 (fotografias das drogas), fls. 126/128 (exame químico-toxicológico), fls. 133/137 (laudo pericial) e pela prova oral.

De igual forma a autoria restou comprovada, recaindo nos acusados.

A prova dos autos demonstra que os entorpecentes e petrechos apreendidos pertenciam aos acusados e se destinavam ao comércio ilícito, mormente pelas condições da abordagem e quantidade de droga apreendida. Com efeito, as narrativas dos policiais foram uníssonas e coerentes, afirmando que durante patrulhamento notaram que o veículo ocupado pelos acusados tentou arrancar bruscamente quando avistada a viatura. Feita a abordagem apreenderam celulares e dinheiro com os acusados. Em seguida, durante as buscas no interior do veículo, localizaram nove tijolos de

maconha sobre o banco traseiro. Afirmaram também que por indicação do corréu Paulo, na casa deste, apreenderam diversos petrechos, inclusive balanças, além de outros dezesseis tijolos menores da mesma droga.

Ressalto a apreensão de vários petrechos, inclusive balanças, instrumentos reconhecidamente usados em crimes do tipo (fls. 133/137).

É certo que o corréu Lucas nega qualquer participação no crime, contudo, a prova dos autos comprova que também transportava a droga. Ora, era ele quem conduzia o veículo e tentou empreender fuga quando visualizou a viatura policial. Ademais, tratava-se de quantidade expressiva de droga, que estava sobre o banco traseiro do carro, não sendo crível que não a tivesse visto.

Assim, além da quantidade de droga apreendida, para a solução do delito em tela outras circunstâncias são observadas, tais como o local da apreensão, as condições da prisão, a profissão exercida, a apreensão de petrechos, etc. Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida dos acusados, no caso, não tendo sido trazidos aos autos elementos que conduzam à certeza quanto à possibilidade de poderem incursionar pela seara do uso de drogas. De igual forma não restou comprovada a origem lícita do numerário apreendido.

Quanto ao valor dos depoimentos de policiais, como são servidores públicos, fielmente compromissados com o bem e a defesa da coletividade (o dever funcional de um policial, em sentido estrito, é prevenir e reprimir o crime), presume-se que agem corretamente e são dignos de credibilidade, mormente porque não há nos autos nenhuma notícia de que teriam motivo para imputar acusação falsa aos réus.

Aliás, como já se decidiu, “Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas porque são policiais não estão não impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos pequeno valor, sobretudo se os mesmos estão em harmonia com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos usuários da fase inquisitorial” (TJ-DF, Ap. 20030110632367APR, 1ª T., Rel. Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p. 180).

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada” (STJ, HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

“Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 - Materialidade delitiva e autoria demonstradas. A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei. Prova - Palavras de Servidores Públicos - Validade -

Inexistência de motivos para incriminarem o réu injustamente. Penas fixadas acima do mínimo legal, em razão da reincidência. Regime prisional fechado. Recurso provido" (TJ-SP, Apelação nº 0010112-19.2016.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Machado de Andrade, v.u., j. 5 de julho de 2018).

Vale ressaltar ainda que para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (descrição da lei), o que, neste caso, constitui o fato de os réus transportarem e armazenarem os entorpecentes apreendidos, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, comprovadas a autoria e materialidade, passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, fixo as penas acima do piso, em 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, no mínimo a unidade. Para tanto, considero a grande quantidade de droga apreendida (25 tijolos de tetrahydrocannabinol – maconha, pesando 6.6233 gramas).

Na segunda fase, quanto ao corréu LUCAS, incide a agravante da reincidência (fl. 68), razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 8 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa, no mínimo a unidade. Já para o corréu PAULO não há agravante nem atenuante a ser considerada.

Na terceira fase descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Ora, neste caso, o acusado LUCAS ostenta outra condenação, sendo reincidente, logo, fica afastada a aplicação do redutor.

Vale ressaltar que a reincidência deve ser utilizada tanto para agravar a pena na segunda fase, como para afastar a incidência do redutor previsto na Lei de Drogas e isto não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, conforme reiteradas decisões do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. ÚNICA CONDENAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA E NEGAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MODO FECHADO ADEQUADO. DETRAÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO À INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)

2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

3. Reconhecida pela Corte de origem a reincidência do paciente, torna-se incabível a aplicação da mencionada benesse, porquanto não preenchidos os requisitos legais. Precedente.

4. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda que decorrente de apenas uma condenação transitada em julgado, pode ser utilizada para agravar a pena e, concomitantemente, para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem se falar em bis in idem. Precedentes.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido" (HC 391152/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta

Turma, j. 18/04/2017, De 25/04/2017, grifo meu).

Com relação ao corréu PAULO, embora seja primário, sem antecedentes criminais e não havendo notícia de que integre organização criminosa, está comprovado que se dedicava a atividades delituosas.

Com efeito, o legislador, ao editar a lei de drogas, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, conseqüentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Em outras palavras, para a situação do mercador novato, aquele de pequena expressão, conhecido como "traficante de primeira viagem", como se pode classificar aquele que possui "estoque" diminuto para negociar durante curto período e, em regra, suprir o próprio vício. Portanto, para esse tipo de traficante é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo.

A doutrina e a jurisprudência apontam situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens para porções individualizadas, balanças de precisão ou, ainda, quantidade e variedade de drogas apreendidas.

Pois bem. O caso em tela revela não se tratar de "iniciante". Com efeito, a par da primariedade, a própria dinâmica fática, revelou circunstâncias delitivas extremamente desfavoráveis. Estava em local conhecido pelo tráfico de drogas e no transporte da droga. Ademais, foram apreendidos em sua residência diversos petrechos, como balança de precisão, com resquícios de material vegetal seco, bem como faca, também com resquícios de substância de cor esverdeada, a comprovar que sua residência servia para o fracionamento e o embalo da droga, dedicando-se o acusado a atividades ilícitas. Se era a primeira vez que guardava drogas não teria tais petrechos e ainda sujos. Temos ainda a apreensão de expressiva quantidade de droga, somente obtida em contato direto com organizações criminosas, o que é notório, trazendo elevado risco à saúde pública, além da mitigação não ser direito subjetivo. Saliento que a quantidade de drogas está sendo utilizada de forma supletiva para afastar o redutor legal.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, ficam definitivas as penas lançadas acima.

Fixo o regime inicial para o cumprimento da pena de prisão no fechado. Além de o corréu Lucas ser reincidente, eles foram surpreendidos transportando expressiva quantidade de drogas, de sorte que a gravidade concreta do delito se revela totalmente incompatível com regimes menos gravosos.

Ressalto que a fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social. Ademais, a quantidade de droga apreendida justifica o regime mais severo.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. TRÁFICODE ENTORPECENTE. CAUSA DE AUMENTO DO INC. III DO ART. 40 E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (STF, HC 161247/SP, AG.REG. NO HABEAS CORPUS, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 22/02/2019, Órgão Julgador: Segunda Turma, v.u.).

"Ementa: REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. MODO MAIS GRAVE JUSTIFICADO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A quantidade de entorpecente apreendido justifica a manutenção do modo prisional mais gravoso, consoante vem decidindo esta Corte Superior de Justiça.

2. Na espécie, estabelecida a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, proporcional o estabelecimento do regime mais severo, ante a quantidade do entorpecente. Exegese do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em combinação com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

3. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no HC 458375/SC, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS

2018/0168683-8, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, j. 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

Os réus estão presos. Nego o direito ao recurso em liberdade. O crime que cometeram e as penas a que estão submetidos, nesta sentença, são suficientes para retratar suas periculosidades se soltos, de modo que a prisão se sustenta na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ademais, como permaneceram presos durante a tramitação do processo, seria um contrassenso que, sem o primeiro título de condenação, a sentença, houvesse motivo para manutenção do cárcere. E, depois, com a definição da culpa (ou pelo menos a primeira definição ruma à culpa), tivessem o direito de deixar a prisão.

Assim, já se decidiu: "Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. (...) Direito de apelar em liberdade. Réu que permaneceu custodiado ao longo do processo. Prisão preventiva. Fundamentação. I - O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. (Precedentes do STJ e do STF). II - A exigência da prisão provisória para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. (Súmula n. 09 do STJ). (...) III - Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantir ao paciente a revogação da prisão cautela (Precedentes). Writ denegado" (HC 62882/RS; Ministro Felix Fischer, j. 07/11/2006, DJ 12.02.2007, p.285).

O presente caso não comporta aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois, com a prisão provisória, ainda não alcançaram o tempo que lhes permitiria a progressão de regime.

Ante ao exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar os corréus:

PAULO SERGIO VILANUEVA TORRES como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa, no mínimo a unidade; e

LUCAS VINICIUS DE FARIA CARDOSO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 816 dias-multa, no mínimo a unidade.

Cada dia-multa deverá ser calculado sobre um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e devidamente corrigida, nos termos do art. 49, do Código Penal.

Como exposto acima, sem direito a recurso em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontram.

Nos termos da Lei 11.608/03, condeno os réus ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs.

Comprovado o tráfico de drogas, decreto o perdimento dos celulares, dinheiro e veículo apreendidos, em favor da União, na forma requerida. Com efeito, não foi comprovada a origem lícita dos bens apreendidos e com relação ao veículo basta que seja utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes para a decretação de seu perdimento, como medida desestimuladora da conduta ilícita. Com o perdimento do bem fica prejudicado o pedido de restituição feito a fls. 249/253.

Agora, com a sentença decretada, estando o laudo definitivo da droga nos autos, determino a destruição da contraprova armazenada, servindo esta como ofício.

Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se à Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos dos réus (art. 15, inc. III, da Constituição Federal).

P. C. I. C.

São José do Rio Preto, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA